

RECURSO CÍVEL Nº 5080284-95.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRENTE: ROBERTO ANDRE GASPAR (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. ART. 40, §19, CF/88. INTEGRAÇÃO À BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PAGAMENTO DE ATRASADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. PRECEDENTES DO STJ. EDCL NO RESP 1192556/PE - REPETITIVO E RESP 1607418/RS. PARCELA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA E PERMANENTE QUE INTEGRA A BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA E TERÇO DE FÉRIAS. ARTIGOS 41, 63 E 76 DA LEI Nº 8.112/90. EVENTUAIS DIFERENÇAS DEVEM SER APURADAS EM SEDE DE CUMPRIMENTO COM REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS, SENDO POSSÍVEL INCLUSIVE A COMPROVAÇÃO CONTÁBIL NESSE MOMENTO, DE QUE A VERBA JÁ COMPÕE A BASE DE CÁLCULO CONCRETO EM RELAÇÃO AO ACRÉSCIMO DE FÉRIAS OU À GRATIFICAÇÃO NATALINA, QUANDO ENTÃO NÃO HAVERÁ O QUE EXECUTAR FRENTE A ESSA VERBA. RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO DA PARTE RÉ E NEGAR PROVIMENTO AO MESMO e VOTO POR CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA E DAR PROVIMENTO AO MESMO nos termos da fundamentação. Sem custas. Condenação da recorrente vencida em honorários de 10% sobre o valor da condenação. Intimadas as partes e decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2025.

5080284-95.2024.4.02.5101

510015492711 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5080284-95.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRENTE: ROBERTO ANDRE GASPAR (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trato de ação em que a parte autora pretende a condenação da parte ré para que integre a verba abono de permanência na base de cálculo do adicional constitucional de terço de férias e da gratificação natalina, bem como o pagamento de diferenças pretéritas do último quinquênio que antecede o ajuizamento da presente ação, acrescidos de correção monetária e juros.

A sentença julgou procedente em parte o pedido inicial entendendo que a gratificação natalina já está sendo paga com o abono em sua base de cálculo.

Recorre a parte autora alegando que a rubrica no SIAPE não é indicativa de pagamento da gratificação natalina com abono na base de cálculo e cim de compensação do desconto efetuado a titulo de contribuição previdenciária sobre gratificação natalina.

Recorre a parte ré alegando que o abono de permanência é verba de natureza compensatória no mesmo valor da contribuição previdenciária descontada do servidor que completou os requisitos para se aposentar e permanece na ativa e não detém natureza

remuneratória. Por fim, pugna pela aplicação do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 no que diz respeito aos juros moratórios e à correção monetária.

VOTO

De início, destaco que esta relatora tem ciência da decisão de afetação constante no âmbito do ARESP nº 2033159/RS, do AResp n. 2.031.906/RS e do REsp n. 1.984.872/CE à sistemática de recurso especial repetitivo pelo STJ. Todavia, não houve determinação de suspensão de julgamento de lides da espécie em instâncias ordinárias.

Quanto à prescrição quinquenal, esta já restou devidamente reconhecida pelo juízo *a quo*.

A questão a ser reapreciada diz respeito à natureza jurídica da verba abono de permanência, que se for remuneratória e permanente deverá integrar a base de cálculo do décimo terceiro salário e terço constitucional de férias, nos termos pedidos pelo recorrido.

Sobre o abono de permanência dispõe a Constituição Federal:

"Art. 40. (...)

(...)

§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)."

Por seu turno, a Lei nº 8.112/90 fala em seu artigo 41 sobre a remuneração do servidor:

"Art. 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei." (grifei)

Quanto à natureza jurídica da verba abono de permanência, se indenizatória ou remuneratória, o STJ consolidou seu entendimento quando do julgamento de embargos de declaração em recurso especial julgado sob o rito dos repetitivos (Tema 424) e decidiu que é verba de natureza remuneratória. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1. Por inexistir fundamento constitucional suficiente, por si só, para manter o acórdão do Tribunal de origem quanto à questão impugnada no recurso especial, não há falar em incidência da Súmula 126/STJ.

2. Esta Seção manifestou-se sobre a natureza jurídica do abono de permanência, quando prestigiou, no acórdão embargado, o entendimento da Segunda Turma, que, ao julgar o REsp 1.105.814/SC, sob a relatoria do Ministro Humberto Martins, reconheceu a incidência do imposto de renda sobre o aludido abono com base nas seguintes razões de decidir: "O abono de permanência trata-se apenas de incentivo à escolha pela continuidade no trabalho em lugar do ócio remunerado.

*Com efeito, é facultado ao servidor continuar na ativa quando já houver completado as exigências para a aposentadoria voluntária. A permanência em atividade é opção que não denota supressão de direito ou vantagem do servidor e, via de consequência, não dá ensejo a qualquer reparação ou recomposição de seu patrimônio. **O abono de permanência possui, pois, natureza remuneratória por conferir acréscimo patrimonial ao beneficiário e configura fato gerador do imposto de renda, nos termos do artigo 43 do Código Tributário Nacional.**" (grifou-se). Com efeito, o abono de permanência é produto do trabalho do servidor que segue na ativa, caracterizando inegável acréscimo patrimonial, o que enseja a incidência do imposto de renda. Não cabe a alegação de que o abono de permanência corresponderia a verba indenizatória, pois não se trata de ressarcimento por gastos realizados no exercício da função ou de reparação por supressão de direito.*

3. Verificar se o acórdão embargado enseja contrariedade a normas e princípios positivados na Constituição é matéria afeta à competência do Supremo Tribunal Federal, alheia ao plano de competência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo que

para fins de prequestionamento, conforme entendimento da Corte Especial (EDcl nos EDcl nos EREsp 579.833/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 22.10.2007).

4. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp 1192556/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/10/2010, DJe 17/11/2010)

Em sequência, o STJ também tem forte jurisprudência sobre ser o abono de permanência verba permanente, afastando o caráter transitória, posto que somente se extinguirá com a aposentadoria do beneficiário, Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. TRIBUTÁRIO. ABONO DE PERMANÊNCIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. A orientação da Corte Especial do STJ é no sentido de que, em Execução contra a Fazenda Pública, é possível a expedição de precatório referente à parcela incontroversa do crédito, ou seja, em relação ao montante do valor executado que não foi objeto de Embargos à Execução.

3. Cumpre registrar que, no âmbito federal, a orientação do STJ foi consolidada na Súmula 31/AGU, in verbis: "É cabível a expedição de precatório referente a parcela incontroversa, em sede de execução ajuizada em face da Fazenda Pública."

4. O abono de permanência é indubitavelmente vantagem pecuniária permanente, pois essa contraprestação se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível ao ocorrer a reunião das condições para a aposentadoria. Não é, portanto, possível atribuir eventualidade ao pagamento da citada vantagem, pois somente com o implemento da aposentadoria ele cessará. (grifei).

5. O STJ, sob o regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008, já se manifestou sobre a natureza jurídica do abono de permanência para fins tributários, de forma a assentar o seu caráter remuneratório.

6. O mesmo se diga em relação ao auxílio-alimentação, porquanto o Superior Tribunal de Justiça entende que tal verba, quando paga em dinheiro, possui natureza remuneratória.

7. Recurso Especial desprovido.

(REsp 1607418/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 12/09/2016)

Ressalte-se que a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a discussão sobre a natureza do abono de permanência é de âmbito infraconstitucional (ARE 1273308 / RS - Relator(a): Min. GILMAR MENDES - Julgamento: 27/08/2020; RE 758345 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/10/2017, DJe em 17/04/2018).

Assim, conjugando-se as normas legais e o entendimento do STJ sobre o tema, entendo correta a sentença que julgou procedente o pedido autoral e considerou o abono de permanência de natureza remuneratória e permanente que deve integrar a base de cálculo da gratificação natalina e do terço constitucional de férias, nos termos dos artigos 63 e 76, ambos da Lei nº 8.112/90. No entanto, a sentença excluiu da condenação a parcela referente à gratificação natalina por já considerar o pedido satisfeito na seara administrativa.

Nesse particular entendo que é possível que a tese autoral e recursal da parte autora esteja correta, vejamos:

O pedido diz respeito ao direito de ter a verba recebida a título de abono de permanência incluída na base de cálculo da gratificação natalina e do terço constitucional de férias. A rubrica incluída automaticamente pelo SIAPE no contracheque do autor, denominada ABONO PERMAN EC 41/03 GRAT refere-se à compensação do desconto efetuado a título de contribuição previdenciária sobre a gratificação natalina e o seu valor não integra o montante pago a título de gratificação natalina.

Portanto, a pretensão (de correção da base de cálculo da gratificação natalina) não está atendida pelo pagamento da rubrica ABONO PERMAN EC 41/03 GRAT no seu contracheque.

Nada obstante, trago importante observação procedida por esta Turma, no que tange ao cumprimento de sentença para a hipótese vertente, nos autos do processo nº 5002383-71.2022.4.02.5117, de Relatoria da Dra Daniella Motta, julgado na sessão virtual de 08/11/2022. Segue trecho do voto:

"Ocorre que, recentemente, em razão de questionamentos em sede de cumprimento, em lides análogas, apurou a contadoria judicial que a base de cálculo da gratificação natalina, conforme os protocolos de cálculos, já inclui o valor do abono de permanência

Ao passo que para cálculo do terço de férias, o abono de permanência não integra sua base de cálculo.

Destaco que, ao que se observa das fichas financeiras dos servidores, o abono de permanência é pago em rubrica própria, como crédito autônomo, compensando o débito de PSS.

Remetido aos autos à Contadoria Judicial constatou-se que ao menos para os servidores do Poder Executivo Federal já há inclusão do abono de permanência na base de cálculo da Gratificação Natalina, o mesmo não ocorrendo com relação ao terço de férias.

De forma que, para a gratificação natalina não há, a priori, lide. Contudo, considerando que não se sabe desde quando essa forma de cálculo foi adotada, bem como se para os demais poderes a sistemática é a mesma, entendo que o mais adequado é reconhecer o direito, devendo as eventuais diferenças serem apuradas em sede de cumprimento com realização de cálculos concretos, sendo possível a apuração de cálculo zero no tocante a Gratificação Natalina.

Nesse sentido, cito os cálculos efetuados no processo nº 5002383-71.2022.4.02.5117/RJ, considerando as fichas financeiras constantes dos autos como paradigmas (evento 59 - inf 1 e evento 1, finanac8). Outrossim, como o abono de permanência é uma verba estipendial permanente remuneratória, paga como verba própria a crédito no valor do PSS deve fazer parte da base de cálculo tanto da gratificação natalina, como já faz, assim como do terço de férias.

Por fim, destaco que o legislador constitucional poderia ter determinado a imunidade de PSS como forma de incentivo a manutenção da atividade. Contudo, não o fez desta forma, mas sim com pagamento de verba permanente no valor máximo correspondente a contribuição. Por conseguinte, não vislumbro razão para incluir o abono na base de cálculo da gratificação natalina e não no terço de férias. O fato de haver isenção legal quanto ao adicional de férias no tocante ao PSS não altera sua base de cálculo (parágrafo primeiro do art. 4 da Lei 10.887/2004)."

Desse modo, o pleito deve ser julgado inteiramente procedente, inclusive com a condenação à inclusão do abono de permanência na base de cálculo da gratificação natalina, mas deve ser permitido que, em sede de execução, caso se verifique contabilmente que o acréscimo de férias ou a gratificação natalina aqui reclamadas já são pagas pela Administração com o abono de permanência na composição da sua base de cálculo, não haverá o que se executar em relação às diferenças em questão.

Isto posto, VOTO POR CONHECER DO RECURSO DA PARTE RÉ E NEGAR PROVIMENTO AO MESMO e VOTO POR CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA E DAR PROVIMENTO AO MESMO nos termos da fundamentação. Sem custas. Condenação da recorrente vencida em honorários de 10% sobre o valor da condenação. Intimadas as partes e decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem.